

1500696-36.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... além de praticar crime permanente, tráfico, resumido na manutenção da droga para o fim de traficar.

Mesmo que não houvessem sido pilhado(s) vendendo a droga, a denúncia é certa em o(s) acusar de manter em depósito drogas, para tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500696-36.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500696-36.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2084891/2022 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 23912026 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 2084891 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ LEONARDO DA SILVA BACELAR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

VISTOS.

JOSÉ LEONARDO DA SILVA BACELAR e MAYCON MOÇO OLIVEIRA, estão sendo processados como incursos nas sanções do artigo 33, "caput" e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, c. c. artigo 69, "caput", do Código Penal, acusados de no dia 28 de março de 2022, por volta de 11 horas, na Rua Dalmo Florence, 160, bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, terem se associado para o fim de cometer, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, "caput" e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343, de 23-8-2006. Acusados também de no local acima citado, no dia 28 de março de 2022, por volta de 11 horas, manterem em depósito, com a finalidade de tráfico, três "kits", com trinta invólucros plásticos fechados por nó encerrando porção de fragmentos ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos com peso de 49,2 gramas, na qual foi detectada a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), e um invólucro plástico fechado

por nó encerrando porção de fragmentos ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos com peso de 74,1 gramas, na qual foi detectada a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e R\$ 80,00 que deve ser tido com produto do tráfico.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação.

A denúncia foi recebida em 20 de maio de 2022 (fls. 197/199) e os réus foram citados (fls. 232 e 234).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação e três testemunhas de Defesa. Ao final, os réus foram interrogados.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, com as condenações dos réus, provadas as ocorrências dos crimes, em concurso material; materialidade e autoria de cada qual. Discorre sobre penas e regimes (fls. 274/277).

A Defesa reclama pela absolvição dos acusados por insuficiência probatória. Os réus negaram os fatos. As testemunhas policiais não realizaram diligências que comprovassem as suas alegações. Não havia provas de que a droga apreendida dentro do imóvel não era para consumo próprio ou que tivessem intuito lucrativo. Invoca o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição com relação ao crime de associação para o tráfico. Não ficou comprovado o vínculo associativo ou reunião estável dos acusados com a finalidade de traficar. O mero concurso de agentes não agravaria por si só a situação de uma eventual conduta de traficância. Cita doutrina e jurisprudência. Por fim, alternativamente, pleiteou que o acusado José Leonardo seja responsabilizado pelo entorpecente apreendido em seu poder, com a desclassificação do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, para o tipo capitulado no artigo 28 da mesma Lei. Foi imputada aos acusados a posse de 123,3 gramas de maconha, o que fugia dos padrões de normalidade em casos de suposta traficância. Para o caso de condenação, pretendia redução da pena, aplicando-se a diminuição na fração de 2/3 pela primariedade (artigo 33, par. 4º). Não houve violência ou grave ameaça. Os acusados não pertencem a organização criminosa e não foi comprovado que eles se dedicassem a atividades criminosas. Fariam jus à substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, com regime brando. Pena mínima, facultado recurso em liberdade (fls. 278/290).

É o relatório.

DECIDO.

Tratando-se os presentes autos de réu preso por furto e encontrando-se o juiz titular da vara usufruindo período de férias (20 dias), sentencio, com amparo no seguinte entendimento jurisprudencial:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. FÉRIAS DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC AUTORIZADA PELO ART. 3º DO CPP. DECISUM COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre que a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução criminal seja congruente com as provas produzidas sob o crivo do juiz substituído. Precedentes: HC 104.075, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 1º.07.11; HC 107.769, Primeira Turma Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.11.11. 2. O artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao Processo Penal, conforme autorização prevista no art. 3º, do CPP, veicula exceção à regra prevista no artigo 399 do mencionado Estatuto Processual Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/08, consistente na possibilidade de o feito ser sentenciado por juiz substituto nas hipóteses de convocação, licenciamento, afastamento, promoção ou aposentadoria do magistrado que presidiu a instrução criminal. 3. O afastamento do juiz titular por motivo de férias autoriza a prolação da sentença por seu substituto, nos termos do artigo 132 do CPC. Precedentes: HC 112.362, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18.04.13; e RHC 116.205, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.04.13. 4. “O princípio pas des nullités sans grief -

corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.') - impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício" (HC 107.822, Primeira Turma, que de fui Relator, DJ de 08.013.12). No mesmo sentido: HC 103.532, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.10.10; HC 104.648, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26.11.13; HC 114.512, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08.11.13). 5. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (mês) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juiz substituto, em razão do gozo de férias do magistrado que presidiu a instrução criminal, e há congruência entre a condenação e as provas colhidas no curso instrução criminal presidida pelo magistrado titular. De resto, não é crível que o Magistrado substituto tenha sentenciado sem conhecimento dos autos. 6. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido, mas desprovido. (RHC 123572, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

No mérito, a denúncia procede.

Ao ser preso em flagrante, José Leonardo disse que encontrava-se em sua casa, quando foi alertado de que policiais estavam em sua casa, a procura de drogas. Inicialmente, negou que tivesse drogas na casa e autorizou que realizassem buscas no imóvel. Os policiais encontraram os entorpecentes, escondidos dentro de um cesto de lixo. Após a localização, confirmou para os policiais que a droga estava lá, mas não lhe pertenciam, sendo que os donos eram a pessoa de nome Maycon e também uma mulher de nome Fernanda, eles eram cunhados. Fernanda era casada com 'Nei', que estava preso. Eles pagariam R\$ 50,00 (cinquenta reais) em determinado período, para guardar as drogas. Apenas recebeu esse dinheiro uma vez, nunca mais pagaram. Assim agiu porque precisava do dinheiro e por temer represálias (fls. 06). Perante a autoridade policial, Maycon asseverou que foi abordado por policiais, que informaram que investigavam tráfico de drogas. Procederam a abordagem e o revistaram, os policiais encontraram apenas o valor de R\$ 80,00 (oitenta reais), certo que esse dinheiro é fruto de seu trabalho com reciclagem. Não pegou nenhuma droga com o mesmo, negava a prática da venda de drogas. Nunca foi preso anteriormente. Era usuário de maconha. Não conhecia o outro abordado (fls. 07). No interrogatório judicial, o réu José Leonardo alegou que era usuário de maconha. Estava dormindo, quando acordou, os policiais já estavam dentro da sua casa. Os agentes de autoridade encontraram as drogas que possuía, destinadas para o seu consumo. Não conhecia Maycon, ele nunca foi até a sua casa e não tinha nada a ver a droga que havia comprado. Não falou nada e não assinou nenhum documento na Delegacia. Trabalhava em uma empresa de açúcar.

Em juízo, Maycon alegou que estava sentado na frente da sua casa, esperava sua mãe para ir ao trabalho. Portava a quantia de R\$ 80,00 no bolso, iria abastecer a caminhonete da sua mãe. Coletavam reciclagem no bairro. Negou ser traficante, não realizou nenhuma venda de drogas. Era pai de família, apenas esperava a chegada de sua genitora. Trabalhava desde os quinze ou dezesseis anos de idade, sempre teve a carteira registrada. Negou ter ido até a casa de José Leonardo, não o conhecia. Foi abordado e conduzido até o local. Os policiais apareceram com as drogas e o acusaram de ter envolvimento com os entorpecentes. Não tinha passagem criminal.

As versões não convencem e não tem esteio probatório.

Emerson Pinto de Siqueira, policial civil, explicou que recebeu uma denúncia, por meio de ligação realizada no telefone fixo da Delegacia. O informante noticiava intenso tráfico de drogas pela Rua Emiliano Pernetá, no Profilurb, tendo enfatizado que as vendas eram frequentes. No bojo dessa denúncia, tinha a descrição física, características e as vestimentas da pessoa que fazia a distribuição dos entorpecentes. O denunciante detalhou que o suspeito utilizava de um imóvel vizinho, como uma base. Pegaram duas viaturas descaracterizadas e foram até o endereço mencionado, para averiguarem a veracidade da denúncia. Assim que estacionaram e iniciaram a observação, perceberam um indivíduo com as

características físicas e vestimentas que constavam na denúncia. O suspeito tinha tatuagens e usava uma camiseta vermelha, conforme descrito na denúncia. Em poucos minutos de observação, constataram que Maycon foi procurado por uma pessoa, deu alguma coisa que ele trazia com ele e em troca, pegou cédula de dinheiro. Isso aconteceu pelo menos duas vezes. Após dois encontros muito similares, Maycon fez um deslocamento a pé, até a Rua Dalmo Florence, uma casa de esquina. Fizeram uma volta com a viatura descaracterizada pelo outro quarteirão, ele entrou na casa e ficou. Após poucos instantes, Maycon saiu e voltou para a Rua Emiliano Pernetta e fez mais uma vez essa movimentação característica, como se fosse de venda de drogas. Ele foi abordado e submetido a revista pessoal. Maycon trazia apenas dinheiro, aproximadamente R\$ 80,00, em dinheiro. Indagado se estava naquele local vendendo entorpecentes, disse que não. Em seguida, deslocaram até a casa em que Maycon tinha acabado de voltar, situado a poucos metros de distância. Na frente do portão da residência, tinha um cachorro, mas o animal não era bravo. Leonardo estava na porta da sala, na frente da garagem, onde foi abordado. Ao ser questionado sobre a existência de algum ilícito dentro do imóvel, visto que receberam denúncia que dizia que estava aguardando droga naquela casa, ele foi taxativo em dizer que não. Leonardo assegurou que não guardava nada lá e autorizou a entrada da equipe no imóvel e acompanhou a buscas realizada pelas equipes policiais. No quarto que ele ocupava, tinha um cesto de roupas sujas. Escondido no meio das roupas sujas, havia uma sacolinha plástica. Dentro dessa sacolinha havia 30 buchas de maconha e um pedaço maior de maconha, que ainda não estava fracionado para a venda, pesando em torno de 80 g. Diante da droga encontrada, Leonardo foi novamente indagado e confidenciou que recebeu uma proposta para guardar os entorpecentes, que eram vendidos na rua. A proposta foi feita pelo Maycon e por uma mulher. Pela guarda do entorpecente na sua residência, ele receberia a quantia de R\$ 50,00, por dia. Diante dos fatos, conduziram os acusados, juntamente com os entorpecentes e o dinheiro até a sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que corroborou a voz de prisão em flagrante e adotou as medidas cabíveis de polícia judiciária. Durante a campanha, ficaram em torno de 20 ou 30 m de distância. Não ficaram ali por muito tempo, em torno de 15 a 20 minutos, pois assim que chegaram, houve movimentação. A rua era bastante movimentada. Não conhecia os acusados, desconhecia se eles eram conhecidos nos meios policiais.

Outro policial civil, Adailton Camargo ratificou a versão, harmônica e coerentemente. Destacou que receberam denúncia anônima, efetuada por meio de ligação no telefone da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. O informante noticiou que havia movimentação de tráfico de drogas na Rua Emílio Pernetta com Godinho da Fonseca, realizada por um rapaz tatuado, que trajava uma camiseta vermelha. Essa mesma denúncia informava que a droga ficava guardada na Rua Dalmo Florence, numeral 160. A autoridade policial determinou que fizessem campanha no local, com viaturas descaracterizadas. Permaneceram longe, mas rapidamente identificaram o Maycon, pois ele agia da seguinte forma: chegaram duas pessoas, ele entregava um pequeno pacote e pegava dinheiro. O suspeito ficava transitando de uma esquina até a outra, até que ele se dirigiu até a Rua Dalmo Florence, entrou na residência, onde permaneceu por um certo tempo e saiu. Posteriormente, outra pessoa encostou, ele entregou em invólucro e pegou uma quantia em dinheiro. Maycon foi abordado e revistado. Em seu poder, apenas localizaram dinheiro. Ele negou que estivesse traficando. Deslocaram-se até a residência situada na Rua Dalmo Florence, onde foram recebidos pelo Leonardo. Ao ser questionado sobre a existência de drogas na residência, ele negou, mas permitiu que verificassem a residência e franqueou a entrada da equipe. Durante as buscas realizadas, localizaram dentro de um cesto de roupas sujas, 30 invólucros de maconha, além de uma pequena peça prensada, que pesava em torno de 80 g. Leonardo informou que a droga não lhe pertencia e que ele estava apenas guardando os entorpecentes para duas pessoas, que identificou como sendo Maycon e sua cunhada, Fernanda. Leonardo esclareceu que guardava as drogas por um determinado período, em troca ele receberia R\$ 50,00. Salvo engano, ele tinha recebido apenas uma parte, que se limitou a esse valor, sob a alegação de que fez isso porque estava precisando do dinheiro. A campanha foi realizada em uma

distância aproximada de 30 ou 40 metros da pessoa de Maycon. Tentavam acompanhar quando ele se deslocava, foi possível verificar que ele entregava algo e pegava dinheiro nas mãos, o que caracterizava a negociação. Não se recordava se alguém filmou a campanha que realizaram. Ficaram no local por aproximadamente vinte minutos, foi uma ação rápida. Não conhecia os acusados.

A testemunha de Defesa André Silva Pessoa esclareceu que antes de ser preso, Maycon trabalhava em uma cooperativa de reciclagem. Ele era funcionário da sua empresa há um ano e três meses, era como um pai para ele. Maycon era casado, ele possui dois filhos. Desconhecia se Maycon tinha envolvimento com drogas ou se ele era dependente químico.

Barbara Luiz Teixeira Leal, outra testemunha de Defesa, afirmou que conhecia Maycon de vista, ele trabalhava com a mãe dele na Cooperativa. Maycon é pai de dois filhos, estava sempre com a família, era um bom pai. Desconhecia que ele tivesse problemas com drogas ou que frequentasse bares.

Por fim, a testemunha de Defesa Raimundo Leandro da Silva Bacelar, irmão de José Leonardo, contou que morava na casa dele. José Leonardo era apenas usuário de drogas (maconha). Maycon nunca entrou na residência em que moravam. Trabalhava das 07 às 17 horas, nunca observou nenhum movimento estranho na residência. Leonardo era trabalhador, tiveram uma boa criação, ele nunca mexeu com coisas erradas. A prova é suficiente para a condenação dos réus, pois.

Após dedicado trabalho de investigação, embasada em informação anônima, que noticiava tráfico de drogas na esquina das Ruas Emiliano Pernetta com Gondin da Fonseca, no Bairro Profilurb. A denúncia detalhava que as drogas vendidas, ficavam guardadas na residência, localizada na Rua Dalmo Florence, n.º 160, nesta cidade. Durante as diligências, identificaram o acusado Maycon, com as mesmas características informadas na denúncia.

Maycon foi observado pelos policiais civis durante uma campanha em atos de compra e venda de drogas, até que entrou na referida casa. Lá, pouco permaneceu, e, ao sair foi abordado, sendo apreendido consigo R\$ 80,00 (oitenta reais), cuja origem não soube explicar, tampouco comprovou ter ocupação lícita.

Os policiais incursionaram no imóvel em que estava José Leonardo, local em que foram apreendidas as drogas, escondidas dentro de um cesto de roupas sujas, em expressiva quantidade.

José Leonardo confidenciou para os policiais que guardava as drogas para Maycon e para sua cunhada, Fernanda, mediante promessa de pagamento, no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), por dia. Alegou, na fase policial, que deixava as drogas em sua casa porque precisava de dinheiro e que temia represálias.

Indisputável, portanto, pela coerência da prova testemunhal e cuidadosa investigação, que toda a droga encontrada era de responsabilidade dos réus, que as mantinham depositadas no imóvel e preparadas para o tráfico, não olvidado o valor dos entorpecentes, como alertado pelos experientes investigadores.

O auto de exibição e apreensão confirma a apreensão da droga, na quantidade informada na denúncia.

Em suma, a prova não autoriza qualquer hesitação quanto ao convencimento da responsabilidade criminal dos réus, mercê das condutas já delineadas, que mantinham em depósito entorpecente, além de praticar crime permanente, tráfico, resumido na manutenção da droga para o fim de traficar.

Mesmo que não houvessem sido pilhado(s) vendendo a droga, a denúncia é certa em o(s) acusar de manter em depósito drogas, para tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado

ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

A quantidade da droga, embalada em porções, sua variedade, é típica de tráfico.

A versão dos policiais civis, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

É do C. STF: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

A grande quantidade e variedade de drogas evidenciam que eles vinham se dedicando a essa atividade criminosa, mediante distribuição de tarefas e de forma minimamente organizada.

Os policiais já tinham informações de que outra(s) pessoa(s) estava(m) associada(s), guardando drogas no imóvel e preparando para tráfico, em quantidade. Há vínculo associativo indiscutível, confirmando-se com as buscas realizadas a plausibilidade da informação anônima lançada à Delegacia Especializada.

O fato de se reconhecer o crime de associação obsta, por evidente, qualquer consideração de tráfico privilegiado.

Na lição de Cleber Masson: "De qualquer sorte, não se aplica a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 "aos réus também condenados pelo crime de associação pra o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei", o qual pressupõe "o dolo de se associar com estabilidade e permanência", fator a indicar seguramente que o agente se dedica às atividades criminosas" (neste sentido, STJ, HC 219.621/TO, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 19.02.2015; STJ, HC 251.677/SP, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 12.11.2014).

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelo laudo de constatação (fls. 10/12), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 145/147).

Daí porque de rigor a condenação.

Fixação das penas.

Os réus são primários. Fixo a pena base no mínimo, em cada crime.

Na segunda fase, não existem circunstâncias para consideração, no tráfico e associação.

Em terceira e última, malgrado primários, não há margem para redução da pena, no tráfico e com base no artigo 33, par. 4º da Lei de Drogas, em face do reconhecimento do crime de associação, pelo qual também restam condenados. Adoto a pena mínima, para cada crime, como definitiva aplicada, reconhecido o concurso material de infrações.

O regime inicial de cumprimento da pena dos crimes deve ser o fechado para os acusados, o que se dá pelo concurso material de crimes, seja porque o tráfico é crime equiparado a hediondo, seja porque este é o único regime suficiente à repressão e prevenção dos delitos em questão, além de adequado à quantidade das penas a serem impostas.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar JOSÉ LEONARDO DA SILVA BACELAR e MAYCON MOÇO OLIVEIRA, cada qual, às penas de cinco (05) anos de reclusão, regime inicial fechado e quinhentos (500) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput' da Lei 11.343/2006 e mais três (03) anos de reclusão, regime inicial fechado e setecentos (700) dias-multa, piso, por infração ao artigo 35, da Lei 11.343/2006, combinadas as infrações com o artigo 69 do Código Penal.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Condeno os réus nas custas do processo, que arbitro em 100 UFESPs, para cada um.

Após o trânsito em julgado, inscrevam-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como dos objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Os réus foram presos em flagrante, tiveram as suas prisões preventivas decretadas.

Agora, sentenciado o processo, interessa a prisão para a eficaz aplicação da lei penal e com regime inicial fechado em relação aos crimes de tráfico e associação criminosa.

Presos preventivamente e tendo respondido a todos os atos do processo reclusos, devem assim permanecer, para garantir a eficaz aplicação da lei penal, a par de manutenção da ordem pública, rotineiramente abalada por crimes de gravidade e hediondo, como o tráfico, em concurso com associação.

Persistem todos os motivos que exigiram o decreto da preventiva e a manutenção deles no cárcere, até esta sentença. E assim devem permanecer, para garantia da aplicação eficaz da lei penal.

(- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

"Não fere o princípio da presunção de inocência a determinação de que o sentenciado se recolha à prisão para aguardar o julgamento de recursos que, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo" (STJ, HC 10.313 SP 5ª T., Rel. Edson Vidigal, 09.11.1999, vu DJ 13.12.1999, p. 165).

E da mesma Corte: "O Plenário do STF já firmou o entendimento de que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos não assegura, de modo irrestrito, o direito ao réu de recorrer em liberdade, ressaltando o disposto na Constituição e nas leis de acordo com ela promulgadas" (RHC 9.342-SP 5ª T., Edson Vidigal 14.12.1999, vu DJ 21.02.2000, pág. 142).

Nesse sentido é a Súmula 9 do STJ e a doutrina (Guilherme de Souza Nucci, CPP Comentado, 6ª ed. RT, 2ª tiragem, maio de 2007, pág. 929), que bem justifica a prisão, na forma do artigo 387, parágrafo único do Código de Processo Penal.

"Em suma, para conciliar todos esses dispositivos e possíveis contradições, deve ser formulada a seguinte interpretação, com as seguintes alternativas: - se o acusado foi preso em flagrante ou por decreto de prisão preventiva, não pode ter fiança ou outra liberdade provisória, inclusive e especialmente após a sentença condenatória - o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, ou o agora comentado, somente pode ter sua aplicação cogitada se o acusado estava solto até a sentença condenatória." (Lei de Drogas Anotada, Vicente Greco Filho e João Daniel Rossi, editora Saraiva, 2007, p.181).

("Não há direito de apelar em liberdade para quem já se encontra preso por força de custódia preventiva, não obstante primário e de bons antecedentes. A norma do art. 594 do Código de Processo Penal só alcança quem ao tempo da sentença condenatória estava em liberdade.") - Boletim do Superior Tribunal de Justiça, n.12, p.62, referindo-se a HC 4.701-0, MG., Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6ª Turma, j. em 12.8.1996;

- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

Recomendem-se os réus.

Americana, 22 de julho de 2022.

EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA